

1500461-77.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... na Travessa Bélgica, conhecida por tráfico, quando visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, entre eles o acusado, com quem foi localizado droga e dinheiro; que ele acabou confessando que estava no tráfico devido a necessidade financeira; que o conduziram à delegacia; que não se lembra com exatidão das drogas, mas tem certeza que havia cocaína e maconha; que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista - SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500461-77.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500461-77.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Adrian Fernando Marques Pereira, na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal (concurso material).

Narra-se na denúncia que "no dia 14 de abril de 2021, por volta de 17h20, na Travessa Bélgica, altura do n. 115 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA, agindo previamente ajustado e com identidade de designios com os adolescentes P.A.O.P. e C.G.L.C., trazia com eles, para fornecimento a terceiros, 55(cinquenta e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 56,0g, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 33,0g, 07 (sete) pedras de crack, pesando aproximadamente 1,0g, e 18 (dezoito) porções e maconha, pesando aproximadamente 41,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de dezoito anos, a saber: Peter Allan Oliveira Pinheiro e Caio Gabriel de Lima Conceição, induzindo os a praticar e com eles praticando as infrações penais acima descritas.

A denúncia foi recebida em .

Citado (fls.), o denunciado apresentou resposta à acusação (fls.).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com o direito de recurso em liberdade.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.), pelo boletim de ocorrência (fls.), pelo laudo de exame pericial (fls.), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

Assim, Claudinei Gomes dos Santos, testemunha, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento na Travessa Bélgica, conhecida por tráfico, quando visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, entre eles o acusado, com quem foi localizado droga e dinheiro; que ele acabou confessando que estava no tráfico devido a necessidade financeira; que o conduziram à delegacia; que não se lembra com exatidão das drogas, mas tem certeza que havia cocaína e maconha; que não se lembra da quantia em dinheiro; que já tinha o visto antes e já o tinha abordado em datas anteriores, mas nada havia sido localizado com ele; que a equipe recebeu várias denúncias de moradores relativas ao acusado no sentido de que estava no tráfico de drogas; que o local é bem próximo a uma escola, mas não se recorda se estava em funcionamento ou não em razão da pandemia; que a ocorrência foi no período da tarde, perto do fim da tarde, ainda estava claro na rua; que havia outras pessoas que transitavam pelo local, um pouco afastados dos três, eles estavam mais no canto da rua, o que despertou a suspeita; que no momento da abordagem o acusado não servia ninguém, só portava a droga; que o local é frequentado tanto por traficantes quanto por usuários.

A testemunha Romário Costa de Souza, policial militar, relatou que se recorda dessa ocorrência de abril, pois foram duas ocorrências em menos de dois meses; que estavam em patrulhamento no bairro Parque Hortênsia, especificamente na Travessa Bélgica, onde é forte o tráfico de drogas; que na rua, próximo a escola, visualizaram três indivíduos em atitude suspeita na lateral da via, e outros indivíduos mais distantes; que já possuíam denúncias de tráfico muito forte ali; que ao se aproximar eles tentaram se evadir e foram abordados de imediato; que lembra que revistou primeiro o maior, identificado como Adrian, e com ele localizaram cocaína, crack e dinheiro; que eram R\$ 100,00, mas das drogas não se lembra quantidade; que localizaram no bolso da calça; que indagado ele confessou a traficância, pois precisava de dinheiro; que os menores disseram que Adrian os convidou; que a outra ocorrência é relativa ao mesmo fato e com o mesmo modus operandi; que por isso foram conduzidos à delegacia; que as denúncias anônimas eram sobre o Adrian e sobre o Peter, menor de idade muito conhecido, salvo engano recolhido à Fundação Casa; que já tinha abordado Adrian anteriormente, mas nada de ilícito encontrou; que a atitude se diferencia de cidadãos comuns pela idade, pela localização, pela forma de avistar a viatura, tentando sair do local; que todas as pessoas seguiram normal, identificando que a viatura está ali para fazer um patrulhamento normal; que inúmeras pessoas que não tem nada também fogem da viatura; que, quando avistaram os três, eles estavam reunidos, a droga e o dinheiro no bolso de Adrian, não estavam vendendo para ninguém; que o IMEI Luiz Gonzaga, na entrada da Bélgica, é de educação infantil, e ao fim do matagal há uma escola estadual; que essa escola é utilizada para fuga, saltando o muro; que, sobre as

denúncias anônimas, possuíam o nome Adrian e características, e principalmente o menor Peter, que é morador dessa rua; que salvo engano já havia abordado Adrian antes desses fatos; que não sabe o endereço de Adrian.

O acusado relatou que foi buscar uma droga e, ao ver a viatura, saiu correndo; que estava com um papelote no bolso, mas era seu, e só tinha dez reais de dinheiro; que tinha ido sozinho e encontrou os menores lá, o Peter e o Caio; que ia comprar droga de um homem que estava lá no mato; que não conversou com ele, só pegou e foi embora; que pagou dez reais por cada droga; que comprou cocaína e só; que o resto da droga não era seu; que a maconha estava consigo também, mas estava no outro bolso; que gastou R\$ 200,00 ao todo; que era um cara alto e branco; que ele estava de short vermelho e branco; que o traficante correu; que disse à polícia que tinha ido comprar e correu; que a polícia não perguntou como era o traficante, não sabia que era importante dar essa informação; que usa pó e maconha; que a droga que pegou dá uma semana; que ia ser internado, mas não foi, fugiu, isso foi agora antes de vir preso; que Peter e Caio falaram que iam comprar também, e ia comprar com o mesmo que correu; que o traficante trafica lá já, não ligou, não sabe o nome; que quem denuncia traficante morre e não fala; que usa droga desde 2016; que tinha 15 anos à época; que seus pais tentaram interná-lo várias vezes e fuge.

Diante do acervo probatório produzido, cumpre notar que, o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado em via pública, juntamente com os dois adolescentes devidamente qualificados, após tentativa de fuga da viatura, oportunidade em que foi revistado e em seu poder foi localizada droga, de espécies variadas, e dinheiro em notas trocadas. Os relatos foram firmes e convergentes. Mesmo após a inquirição promovida pela defesa técnica, não há contradições substanciais e relevantes que indiquem que houve falsidade dos relatos dos policiais ou mesmo formação de falsas memórias. A versão do próprio acusado corrobora a dinâmica da abordagem, tendo em vista que o próprio acusado relatou que estava com os adolescentes, que tentou fugir da abordagem e que realmente possuía consigo drogas em seu bolso; bem como dinheiro.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar que o acusado concorreu para a prática do fato.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos

quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). O que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos. Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

Portanto, é cediço que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) consiste em tipo misto alternativo com 18 (dezoito) núcleos do tipo e sem elementos subjetivos especiais, ao passo que o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para uso pessoal) consiste também em tipo misto alternativo com 5 (cinco) núcleos do tipo, todos eles também constantes do art. 33, mas com a distinção de um elemento subjetivo especial: a destinação do objeto material do crime (droga) ao consumo pessoal.

Diante de tais figuras típicas similares, distintas sobretudo pela destinação da droga, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece os critérios que devem ser considerados pelo órgão julgador para estabelecer se a droga tinha destinação ao consumo pessoal: (i) a natureza e a quantidade da substância apreendida (circunstâncias objetivas), (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação (circunstâncias espaciais), (iii) as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (circunstâncias subjetivas).

Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra probatória que dele decorre, é forçoso reconhecer que a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso (art. 33) depende do afastamento, para além de dúvida razoável, da destinação da droga ao uso pessoal (art. 28), mediante verificação dos critérios legais constantes do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. Do contrário, na situação de dúvida, deve esta ser resolvida em favor do acusado, com a subsunção ao tipo penal menos gravoso, consectário dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei. Nesse sentido, vale conferir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.769.822/PA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2018).

No caso ora em apreço, verifica-se então que foi ventilada em defesa a tese de desclassificação, a qual, porém, está desprovida de elementos que lhe confirmem aceitabilidade e verossimilhança e acaba se revelando divorciada das demais provas produzidas, as quais confirmam de modo íntegro e coerente a hipótese acusatória. Com efeito, embora o acusado tenha relatado que teria ido comprar drogas, verifica-se que foram apreendidas três espécies distintas de drogas (maconha, cocaína e crack), o que por si só fragiliza a tese de consumo pessoal da droga. Tais drogas, além de segregadas em porções individualizadas, foram apreendidas em conjunto com R\$ 100,00 (e não com R\$ 10,00 como alegado em autodefesa). A versão defensiva do acusado, por sua vez, é bastante vacilante. Em um primeiro momento, aponta que só possuía um papelote em seu bolso, para seu consumo. Diz, na sequência, que pegou R\$ 10,00 por cada droga. Indagado sobre qual droga comprou, diz que apenas cocaína. Contudo, na sequência, passa a dizer que comprou também maconha, a qual estaria em seu outro bolso, mas teria se esquecido disso ao responder à pergunta anterior. Passa então a dizer que as duas drogas, juntas, custaram R\$ 200,00. Ventila, ainda, que o traficante estaria no local também teria fugido ao ver a viatura, mas não considerou importante dizer isso à polícia, nem foi perguntado sobre isso pela polícia, o que é, no mínimo, versão inverossímil, dotada de nenhuma ou mínima plausibilidade.

Assim, no caso, a despeito do notável esforço da defesa técnica, não é viável a desclassificação pretendida.

Ainda quanto à tipicidade, porém, cumpre proceder a breve reparo da capitulação do

fato diante do conflito aparente de tipos penais, a fim de afastar a configuração do crime autônomo descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 em concurso material com o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06) em razão da incidência da causa especial de aumento de pena deste crime no caso de porte de arma de fogo, na forma do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da especialidade.

Assim, ante o princípio da vedação ao binômio in idem e o princípio da consunção (absorção), impõe-se a absolvição do acusado no que toca à imputação dos crimes descritos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, ao passo que sobre a pena aplicável ao crime de tráfico de drogas deve incidir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, dada a incidência das hipóteses descritas em seu inciso VI (participação de adolescente). Sobre a questão, vale assentar que a leitura conjunta dos arts. 383 e 384 do CPP revela que a falta de pedido de condenação pela prática de determinado crime na peça acusatória não obsta a condenação, mas sim a falta de narrativa quanto ao fato. Tais dispositivos legais formatam o princípio da congruência (entre sentença e acusação) no direito processual penal, o qual incide em relação aos fundamentos fáticos da pretensão acusatória, mas não em relação à sua fundamentação jurídica ou em relação ao pedido (capitulação jurídica a conduta e sanções penais aplicáveis). Cuida-se de consectário da não vinculação do órgão julgador aos fundamentos jurídicos da demanda, o qual autoriza a assim denominada *emendatio libelli* nos termos expressos do art. 383 do CPP.

Nesse cenário, no caso, deve ser reconhecida a subsunção do fato narrado na denúncia ao tipo penal constante do preceito primário do art. 33, com a incidência da majorante descrita nos art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com a consequente absolvição da imputação do crime descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que há imputabilidade e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes não demonstra a existência de mais uma condenação penal definitiva valorável nesta fase (cf. Súmula 444/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame.

Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais uma espécie de substância ilícita (maconha, crack e cocaína), de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Quanto à quantidade de droga, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e não

incidem agravantes, razão pela qual a pena deve ser atenuada em 1/6 conforme referencial jurisprudencial. A pena provisória é então fixada em 5 anos, 2 meses e 15 dias, mais 520 dias-multa.

Na terceira fase, deve ser reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a qual depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa.

No caso, a certidão de antecedentes comprova o preenchimento dos dois primeiros requisitos. Não há nenhuma condenação penal definitiva (nem há ação penal ou inquérito policial em curso por fato anterior ao presente – fatos posteriores não podem incrementar, retroativamente, a valoração negativa do presente fato).

Quanto aos antecedentes infracionais (fls. 257), podem, em tese, indicar a dedicação a atividades criminosas, razão pela qual devem ser analisados. No caso ora em apreço, verifica-se o seguinte: (i) nos autos n. 0000005-81.2017.8.26.0695 houve homologação de remissão; (ii) nos autos n. 0000419-45.2018.8.26.0695 e nos autos n. 0000779-77.2018.8.26.0695 houve prolação de sentença conjunta que julgou procedente representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por duas vezes, em fevereiro e em abril de 2018 (portanto, mais de três anos antes ao fato ora em apuração); (iii) nos autos n. 1019-37.2016.8.26.0695 houve sentença de arquivamento; (iv) nos autos 0001808-65.2018.8.26.0695 houve instauração de execução das medidas impostas, extintas pelo advento da maioridade. A procedência da representação por dois atos infracionais praticados em curto intervalo temporal (dois meses), ambos há mais de três anos da prática do fato-crime ora em apuração, é por si só insuficiente para indicar dedicação a atividades criminosas.

De outro lado, o acervo probatório deste caso, cujo objeto se concentra, em suma, em uma abordagem policial ocasional e eventual, não demonstra nem a dedicação do agente a atividades criminosas, nem a sua integração a organização criminosa – tanto assim que o próprio Ministério Público requereu o arquivamento em relação ao crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35). O fato posterior àquele ora em apuração não pode interferir no exame da gravidade/reprovabilidade do presente fato-crime.

Logo, é imperativo o reconhecimento da incidência da aludida minorante.

Em relação ao quantum de diminuição, cumpre registrar de início que, quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, como já foram analisadas na primeira fase e consideradas para a fixação da pena-base, deixa-se de valorá-las novamente nesta fase para fixação do patamar da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fim de evitar bis in idem indireto, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM, Plenário, j. 3.4.2014, Tema 712 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, j. 09/06/2021).

Por outro lado, tendo em vista que há antecedentes infracionais, devem obstar a fixação da minorante no máximo e devem então ensejar a fixação no patamar intermediário de 1/3.

De outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (participação de adolescente), a qual é fixada no patamar intermediário de 1/4 em razão da participação de dois adolescentes.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 4 anos, 4 meses e 2 dias, mais 432 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, pois ainda superior a quatro anos de reclusão.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de:

- 1) ABSOLVER o acusado ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA da imputação do crime descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, III, do CPP;
- 2) CONDENAR o acusado ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA ao cumprimento de 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 432 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput e § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas pelo Tribunal de Justiça para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e constatada na instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Fls. 296: expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da

CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nazaré Paulista, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA